

1501872-90.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... o réu na rua em situação típica de tráfico de drogas.

De fato, havia várias denúncias de tráfico feitas por moradores do condomínio existente na frente da praça de que ali estava ocorrendo tráfico de drogas. No dia dos fatos, o réu foi flagrado postado no local e, além de não estar envolvido nas atividades de lazer que ali se realizavam, demonstrou nervosismo ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13419-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501872-90.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501872-90.2021.8.26.0599

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2330182/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 21770582 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 3467/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2330182 - 05º D.P. PIRACICABA, 3467/21/922 - 05º D.P. PIRACICABA, 2330182/2021 - 05º D.P.

PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira

Vistos,

PAULO HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, c.c. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia e seu aditamento (fls.

254), no dia 04 de dezembro de 2021, por volta das 19,00 horas, na Rua Efigênia Mito Cesta nº 182, Bairro Vila Sônia, nesta cidade e comarca de Piracicaba, para fins de tráfico, trazia consigo e tinha em depósito, 38,0g de cocaína, distribuídos em 133 "eppendorfs", substâncias entorpecentes as quais determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que policiais militares abordaram o acusado no local acima mencionado, uma praça pública frequentada por crianças e adultos, e usada para lazer e prática de esportes, e localizaram em sua posse 10 "eppendorfs" de cocaína e a quantia de R\$30,00, proveniente da mercancia ilícita. Na sequência, dirigiram-se até sua residência e encontraram mais 123 "eppendorfs" de cocaína idênticos àqueles encontrados em sua posse, além de R\$897,00, oriundo do narcotráfico, e 390 "eppendorfs" vazios.

Conclui a denúncia que todas as drogas apreendidas pertenciam ao réu e se destinavam ao narcotráfico.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 109). Defesa preliminar apresentada às fls. 202/204. Após, a denúncia foi recebida (fls. 208) e o réu foi citado (fls. 241).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e três arroladas pela defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

Na fase de requerimentos de diligências (fls. 254), o Ministério Público aditou a denúncia para incluir a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei Antitóxicos, afirmando que os fatos ocorreram na frente de uma praça pública frequentada por crianças e adultos e usada para lazer e prática de esportes.

Concedida oportunidade para manifestação da defesa, o aditamento à denúncia foi recebido (fls. 271) e o acusado foi novamente interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade do delito, bem assim a causa de aumento de pena.

A Defesa arguiu nulidade da ação dos policiais e pediu a absolvição, por falta de provas.

É o relatório.

Decido.

Afasto, primeiramente, a tese defensiva de ilicitude da ação dos policiais e conseqüente nulidade da prova dela decorrente em razão da abordagem do réu e posterior busca e apreensão em sua casa sem mandado judicial.

A Constituição Federal expressamente autoriza a busca domiciliar sem mandado judicial em casos excepcionais, como aquele em que há o flagrante delito, dispondo, em seu art. 5º, inciso XI, que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial" - gn.

O crime de tráfico, na modalidade "ter em depósito" substância entorpecente, é permanente.

E, no caso concreto dos autos havia fundadas suspeitas da prática do crime pelo

réu, o que justificou sua abordagem na rua, bem assim a diligência em sua residência.

Revelou a prova oral que adiante será analisada que os policiais flagraram o réu na rua em situação típica de tráfico de drogas.

De fato, havia várias denúncias de tráfico feitas por moradores do condomínio existente na frente da praça de que ali estava ocorrendo tráfico de drogas. No dia dos fatos, o réu foi flagrado postado no local e, além de não estar envolvido nas atividades de lazer que ali se realizavam, demonstrou nervosismo ao notar a aproximação da viatura, agindo de forma a evitar eventual abordagem, atitude típica dos traficantes que ficam vendendo entorpecentes em pontos de tráfico.

Isso motivou a abordagem do réu pelos policiais e seu desdobramento, que se estendeu para o interior do apartamento no qual ele morava, cujo ingresso foi autorizado por ele (os policiais foram uníssonos em afirmar que houve a expressa autorização do acusado, o qual, no interrogatório judicial, também afirmou que autorizou o ingresso, embora tenha alegado que fez isso por medo do que poderiam fazer com sua esposa), e lá encontraram grande quantidade de entorpecentes, dinheiro e eppendorfs vazios, confirmando a prática do crime por ele.

Havendo, portanto, fundada suspeita da ocorrência do crime permanente pelo réu e no seu imóvel, bem assim autorização de ingresso, estão justificadas a abordagem pessoal e a subsequente busca e apreensão sem mandado judicial.

Neste sentido tem se posicionado o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confirmam-se alguns recentes julgados:

“HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Preliminar - Nulidade - Violação de Domicílio - NÃO VERIFICADO – O ingresso dos policiais na residência a priori foi franqueada pelo paciente, após denúncia anônima. Diante de tal contexto, é certa a situação de flagrante, não havendo falar em nulidade da prisão por violação de seu domicílio. Ademais, em se tratando de delito permanente, cujo estado de flagrância se perdura no tempo, a diligência policial, em residência, pode ser feita a qualquer hora do dia ou da noite, prescindindo até mesmo da existência de uma determinação judicial para tanto, em conformidade como disposto no art. 5º, XI, da CF/88. No mérito, insurge-se contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea. Aduz, ainda, que estão ausentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar – IMPOSSIBILIDADE – A decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. De outro lado, remanesçam os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, lastreada na expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas e circunstâncias do fato, elementos a denotar maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social do paciente - Periculum Libertatis – Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ. Ordem denegada”. (TJSP. Habeas Corpus Criminal 2095991-37.2021.8.26.0000. Relator: Paulo Rossi. 12ª Câmara de Direito Criminal. J: 02/06/2021) g.n.

“TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR – Ilícitude da prova. Inocorrência. Invasão de domicílio. Crime permanente e estado de flagrância – Rejeição. MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de considerável quantidade de entorpecente (01 tijolo de maconha com peso líquido de 469,6 gramas), além de dinheiro e faca com resquícios de droga – Desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas. Descabimento – Condenação mantida. PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Atenuante

da menoridade relativa inócua (Súmula nº 231 do STJ) – Inviável o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Apelante que ostenta diversos atos infracionais pretéritos, um deles equiparado ao tráfico e praticado na mesma localidade. Precedentes do STJ – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Apelo desprovido” (TJSP. Apelação Criminal 1518652-88.2020.8.26.0228. Relator: Gilberto Ferreira da Cruz. 15ª Câmara de Direito Criminal. J: 10/05/2021) g.n.

No mérito, a denúncia procede.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos: 1) Boletim de ocorrência de fls. 08/10; 2) Auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e fotografias de fls. 15; 3) Laudo de constatação de fls. 16/18 e pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 151/153, com resultados positivos para cocaína em relação às substâncias apreendidas.

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 06), o réu permaneceu silente.

Interrogado em juízo (gravação), negou o crime e a posse das drogas. Disse que, no dia dos fatos, foi abordado por policiais na beira da pista fumando um cigarro de maconha, na companhia da esposa, com quem tinha saído para levar a cachorra para passear. Os policiais chegaram de forma truculenta e queriam que comesse a droga que estava usando. Não encontraram dinheiro nem porções de cocaína em seu poder. Sua esposa os questionou em razão da forma agressiva como agiam. Eles, entretanto, não lhe deram ouvidos e o agrediram, apontaram arma de fogo em sua direção e dizendo que iriam para sua casa. Com medo do que pudessem fazer, autorizou o porteiro de seu condomínio a liberar a entrada para os policiais. Quando notaram a chegada da polícia, uns moleques que ali estavam saíram correndo em direção a uma mata. Os policiais pegaram as chaves do hall com o zelador e disseram que, como não tinham conseguido pegar os moleques, iriam “pegar” ele (o interrogando) mesmo. Eles fizeram uma busca em seu apartamento e só encontraram o dinheiro apreendido. Lá não havia drogas nem eppendorfs vazios. Eles também invadiram apartamentos de outros moradores. Levaram-no junto até um deles e, enquanto fizeram a busca em seu interior, ficou do lado de fora. Depois, eles saíram com a sacola com as drogas e o acusaram injustamente. Disse que não conhecia esses policiais anteriormente. Por fim, admitiu que na praça existente na frente do condomínio de apartamentos havia área de lazer com equipamentos de ginástica que eram usados pelos moradores.

A versão do réu, além de totalmente inverossímil (não se pode crer que, sem que houvesse qualquer reclamação de outros moradores, ou da administração do condomínio, os policiais tivessem agido de forma tão arbitrária, invadindo diversos apartamentos num condomínio de prédios, apenas com o intuito de recolher uma sacolinha com drogas e imputar a autoria do crime ao réu), foi afastada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 05) e em juízo (gravação), o policial militar Gilmar Pereira da Costa declarou que estava em patrulhamento com seus colegas de farda no bairro Santa Terezinha e, quando passaram pela Rua Efigênia Miotto Cesta, numa praça de recreação, onde há campinho de futebol e brinquedos para crianças, viram o réu na companhia da esposa e de um rapaz, em atitude suspeita, pois não estavam envolvidos nas atividades de lazer que ali se realizavam e o réu demonstrou certo nervosismo ao notar a aproximação da viatura, inclusive, virando-se de costas. Diante disso e da existência de relatos de diversos moradores do condomínio que ficava na frente da praça de que estava ocorrendo tráfico de drogas, resolveram abordá-los. Em revista pessoal, localizaram 10 porções de

cocaína e R\$ 30,00 em dinheiro com o réu. Com o rapaz que o acompanhava nada de ilícito foi encontrado. Questionado sobre os entorpecentes, o réu admitiu que estava traficando e disse que em seu apartamento, que ficava na frente da praça, havia mais entorpecentes. Ele franqueou a entrada no imóvel e lá, dentro do guarda-roupas, encontraram mais 123 porções de cocaína, embaladas de forma idêntica às que foram encontradas na posse do réu, bem assim a quantia de R\$ 897,00 em notas trocadas. Também localizaram 390 pinos vazios que, segundo Paulo, seria usado para acondicionar mais drogas. O acusado assumiu a propriedade dos entorpecentes e disse que estava traficando em razão de estar desempregado, mas não deu o nome de quem lhe fornecia drogas. Disse que, quando entraram no condomínio em que o réu morava, não viram ninguém fugindo. Por fim, afirmou que não conhecia o réu anteriormente e que só realizaram buscas no apartamento dele e em nenhum outro.

No mesmo sentido as declarações prestadas extrajudicialmente (fls. 04) e em juízo (gravação) pelo policial militar Bruno Eduardo da Silva Murari, o qual acrescentou que o réu também admitiu que o dinheiro apreendido era produto do tráfico.

Anoto que os relatos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé. O próprio réu disse que não os conhecia anteriormente, de modo que não se pode imaginar que teriam imputado falsamente um crime a ele, pessoa que sequer conheciam.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a uma pessoa a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confiram-se alguns julgados:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias,

soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação do acusado em detrimento da palavra dos policiais militares: enquanto o interesse destes é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daquele é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Registro que os relatos dos agentes da polícia não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

As testemunhas arroladas pela defesa e ouvidas em juízo (gravação), tentaram confirmar a versão do acusado de que não havia drogas em seu apartamento, mas incidiram em diversas contradições que infirmaram seus relatos.

Com efeito, Monnyck Toledo disse que no dia dos fatos, a esposa do réu chegou do serviço às 17 horas e o réu chegou por volta das 18 horas, tomou banho e saiu com a mulher e com o cachorro, dirigindo-se ambos à praça que ficava na frente do condomínio. Enquanto isso, permaneceu no apartamento deles com as crianças, até que, por volta das 19 horas, os policiais chegaram com Jenifer e o réu e entraram no apartamento. As crianças começaram a chorar e ficou um pouco com elas para acalmá-las na sala, de onde tinha visão de todos os cômodos da casa. Em determinado momento, foi até a cozinha, deixando as crianças sentadas no sofá. Havia 5 policiais. Um ficou parado na porta e os outros passaram a fazer buscas nos diversos cômodos da casa. Viu que, durante a busca, eles encontraram dinheiro porque eles comentaram sobre isso (entretanto, não soube em que cômodo), mas drogas não, pois não a apresentaram para ninguém ali e ouviu um falando para o outro que não tinha encontrado entorpecente. Depois os policiais se reuniram, conversaram e levaram o réu para fora. Durante toda a busca, o réu e a esposa dele estavam no apartamento. Eles ficaram em pé o tempo todo e circularam no apartamento. Ele estava algemado com os braços para trás. Declarou, por fim, que Jenifer, a esposa

do réu, disse que o dinheiro era para pagamento do aluguel e energia; que cuida das crianças do réu esporadicamente há aproximadamente um ano; que ele é usuário de maconha.

Entretanto, a esposa do réu, Jenifer Faria, desmentiu em parte o relato de Monnyck, declarando que, no dia dos fatos, estava com o réu na praça, onde foram levar a cachorra para fazer necessidades. Logo que chegaram, foram abordados por policiais que se aproximaram em duas viaturas. Eles não encontraram nada de ilícito com o réu. A seguir, uma equipe entrou em seu apartamento e outra foi para outro apartamento. Em sua residência, eles encontraram apenas o dinheiro apreendido, que seria usado para pagar aluguel e despesas da casa. Contrariando totalmente o relato de Monnyck, disse que, no dia dos fatos, não foi trabalhar, até porque não trabalha, é "do lar". Afirmou que, naquela data, saiu de casa por volta das 18,30 horas para fazer a sobancelha e retornou pouco depois, por volta de 18,50 horas. Neste momento, o réu estava em casa e, logo que chegou, pegaram a cachorra e foram para a praça, onde, menos de cinco minutos depois, foram abordados por policiais (aqui contrariou a versão do próprio réu, que disse que a abordagem não foi na praça). Afirmou que o réu trabalha das 7 às 17 horas e costuma chegar em casa por volta das 17,10 horas, pois o trabalho é perto. Na sua casa entraram 4 policiais e outros 4 foram num apartamento em andar mais baixo, no bloco ao lado. Novamente contrariando Monnyck, disse que ficou do lado de fora do apartamento com durante a busca. O réu foi levado ao apartamento de baixo com os policiais. Quando retornaram, os policiais estavam com uma sacolinha branca com as drogas e disseram que o réu seria preso e que se não assumisse a propriedade da droga, iriam prendê-la também e os filhos seriam encaminhados ao Conselho Tutelar.

Como se vê, são diversas as contradições entre os depoimentos dessas duas testemunhas e do próprio réu, o que afasta totalmente a credibilidade de seus testemunhos.

Por fim, a última testemunha arrolada pela defesa, o sogro do réu, Pedro Aparecido da Silva, nada soube dizer sobre os fatos. Disse que apenas Paulo trabalha com ele de servente de pedreiro em local distante aproximadamente 10 minutos da casa dele. Desconhece fatos que o desabonem.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que o réu trazia consigo e tinha em depósito, para fins de mercancia, 38,0g de cocaína, distribuídos em 133 "ependorfs", substância que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De fato, sua negativa foi afastada pelos uníssonos e convergentes depoimentos dos policiais militares no sentido de que as drogas estavam, parte na sua posse, e outra parte em seu apartamento.

Registro que o destino mercantil dos entorpecentes apreendidos na posse do réu ficou evidenciado não só pelas circunstâncias da diligência (foi abordado postado em local apontado como ponto de tráfico portando dinheiro e drogas e, ao notar a aproximação da viatura, agiu de forma comprometedor, tentando evitar a abordagem), mas também em razão da quantidade de drogas que ele portava.

Além disso, ele ainda guardava em seu apartamento expressiva quantidade de entorpecente, totalmente incompatível com a situação de mero usuário.

Acrescente-se o fato de, no seu apartamento, terem sido encontrados 390 microtubos vazios, iguais os que são usados para embalar entorpecentes.

Por fim, ele ainda possuía elevada quantia em dinheiro (R\$ 897,00), em notas trocadas, cuja origem lícita não foi comprovada, presumindo-se, nesse contexto, que era decorrente do tráfico de drogas.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

“TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas - Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não espanca a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.” (TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - J. 20/07/2020). g.n.

“MATERIALIDADE – Auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – Comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA – Depoimento de policiais que confirma a abordagem da ré e do menor, cujas características coincidiam com aquelas informadas em denúncia como sendo a dos traficantes, ocasião em houve apreensão de drogas em poder do menor – Confirmação pelos policiais de que o adolescente afirmou que a ré trabalhava junto na traficância, na função de 'olheira' – Validade – Depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – Inocorrência no caso em tela. TRÁFICO – Destinação a terceiros – Quantidade incomum com a figura do usuário – Forma de acondicionamento das drogas, própria para a venda a varejo – Apreensão de dinheiro – Falta de condições econômicas para a ré possuir a droga para seu uso pessoal – Denúncia – De rigor a condenação da ré – Absolvção – Impossibilidade – Negado provimento ao apelo. CAUSA DE AUMENTO – Prática do delito que envolveu adolescente demonstrada pela prova oral – Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. PENA – Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal – natureza da droga de alto potencial lesivo – Manutenção – Presente a atenuante da menoridade – Redução da pena ao mínimo legal – Súmula 231 do STJ – Presente a causa de aumento relacionada com o envolvimento de adolescente – Exasperação da pena em 1/6 – Reconhecido o redutor na fração de 2/3 – Manutenção ante a inércia ministerial – Dedicção da ré à atividade criminosa – Passagem por ato infracional – Apreensão de considerável quantidade de droga – Profissionalização – Dedicção à atividade criminosa – Manutenção porque vedado a reformatio in pejus – Redução da pena – Impossibilidade – Improvimento ao apelo. REGIME – Fechado – Apreensão de elevada quantidade de droga – Natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo – Alta reprovabilidade e periculosidade – Ré que ostenta processo por ato infracional – O regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar a delinquir (Beccaria) – Regime fechado – Necessidade – Improvimento ao apelo”. (TJSP - Apelação Criminal 1502824-11.2019.8.26.0544 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lauro Mens de Mello - J. 16/07/2020) g.n.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 40, inciso III, da referida lei, eis que ficou comprovado que o crime foi praticado nas imediações de área de lazer, usada por moradores da região.

Passo à individualização das penas.

O réu possui maus antecedentes (condenação definitiva por crime de furto no processo criminal nº 25622-24.2002, fls. 154/155 c.c. fls. 99, com pena julgada extinta pela prescrição da pretensão executória em 30/09/2014).

A teor do julgado pelo C. STF no RE 593818 (com repercussão geral reconhecida - Tema 150), referidas condenações não podem ser desprezadas.

De fato, no mencionado recurso extraordinário, decidiu a Corte Suprema que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para a fixação da pena-base em novo processo criminal, podendo subsidiar a discricionariedade do julgador na fase de dosimetria da pena.

As demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis.

A quantidade de drogas, embora mais expressiva a ponto de indicar o tráfico, não fugiu à normalidade da espécie.

Assim, em razão dos maus antecedentes, fixo as penas-base em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Não se fazem presentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Com fundamento no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06 (crime cometido em local de recreação), aumento as penas para seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa.

Inexistem causas de diminuição de penas.

Registro que, por expressa disposição legal, os maus antecedentes impedem a aplicação do redutor do parágrafo 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06.

Ademais, além de possuir maus antecedentes, o que indica reiteração criminosa, o réu tinha em depósito não só entorpecentes para fins de tráfico, mas também expressiva quantia em dinheiro e considerável quantidade de eppendorfs vazios, o que indica que exercia tráfico de maior expressão, não se tratando de pequeno e eventual traficante.

Tais circunstâncias impõem a fixação de regime fechado para início do cumprimento da pena corporal, sem possibilidade de substituição por restritivas de direitos ou concessão de sursis, os quais também são incabíveis em razão da quantidade de pena imposta.

Acrescente-se a isso as graves consequências do delito de tráfico, que fomenta a prática de vários outros crimes, destrói famílias, vidas e a saúde dos usuários, que dificilmente conseguem se livrar do vício.

Eleição de regime diverso e aplicação de penas substitutivas, no caso concreto dos autos, impediriam que a pena cumprisse suas funções de prevenção e reprovação dos crimes, pois não fariam com que o réu sentisse as consequências de seu grave ato.

Há várias decisões de nossos Tribunais no sentido de que é possível a eleição do regime fechado, sem substituição por restritivas de direitos, no crime de tráfico de drogas se a natureza, a vida pregressa e as circunstâncias concretas do crime indicarem tratar-se de agente de maior periculosidade.

Confira-se julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recursos ministerial e defensivos – Nulidade da sentença – Corréu ouvido previamente à testemunha inquirida por carta

precatória - Irrelevância - Inteligência do art. 222, § 1º, do Código de Processo Penal - Preliminar rejeitada - Materialidade e autoria incontroversas - Condenações mantidas - Maus antecedentes que justificam o aumento das penas-base - Inaplicabilidade do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas - Regime inicial fechado de rigor para ambos corréus - Impossibilidade de substituição das penas corpóreas pela restritiva de direitos - Preliminar rejeitada, recursos defensivos desprovidos e provido o recurso ministerial". (TJSP - Apelação Criminal 0005848-49.2014.8.26.0366. Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Roberto Porto - j. 23/02/2021) - g.n.

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Apelo do réu - Pleito de relaxamento da prisão sob o argumento de sua ilegalidade em virtude do descumprimento do disposto no parágrafo único, do art. 316, do CPP - Não acolhimento - Ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva durante a instrução criminal superada diante do reexame da matérias na sentença condenatória - Precedentes do STJ - Tese de nulidade processual por cerceamento de defesa - Insubsistência - Patrono do réu que deixou de apresentar rol de testemunhas no momento oportuno (defesa prévia) - Questão alcançada pela preclusão temporal. PRELIMINAR REJEITADA. Mérito - Pleito de absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelas provas coligidas - Ausentes motivos idôneos para retirar a credibilidade dos relatos dos policiais responsáveis pela diligência - Condenação de rigor - Dosimetria que não comporta modificação - Inviabilidade de aplicação do redutor previsto no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 - Recorrente portador de maus antecedentes - Particularidades da hipótese a evidenciar que ele se dedicava de habitualmente ao comércio vil - Regime prisional fechado mantido - Restituição do veículo apreendido - Descabimento - Automóvel empregado de forma reiterada na prática do tráfico de drogas - Perdimento do bem decretado nos termos do art. 63, da Lei de Drogas - Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO". (TJSP - Apelação Criminal 1523191-34.2019.8.26.0228. Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Cesar Mecchi Morales - j. 02/03/2021) - g.n.

Registro que o reconhecimento dos maus antecedentes para fins de impedir a concessão de benefícios ao acusado e apená-lo de forma mais grave não fere a coisa julgada, nem constitui "bis in idem", pois não se trata de punir o agente duas vezes pelo mesmo fato.

Como bem ensina Guilherme de Souza Nucci, essa ideia "peca pela simplicidade. O sistema de fixação de penas obedece a outro preceito constitucional, merecedor de integração com os demais princípios penais, que é a individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF)" (CPComentado - RT, 13ª ed., pag. 464).

Ao se reconhecer os maus antecedentes e aumentar a pena do crime em razão dessa circunstância desfavorável ou deixar de aplicar ao réu alguma benesse, o Estado nada mais faz do que punir com maior rigor o agente que, tonando a delinquir, desafia a ordem pública e as leis vigentes, demonstrando, no dizer do professor Nucci, "persistência e rebeldia inaceitáveis para quem pretenda viver em sociedade. Destarte, sofre uma punição mais severa" (obra citada, pag. 464).

Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico. APELAÇÃO CRIMINAL - PENA E REGIME PRISIONAL - Pena fixada com critério e corretamente - Reincidência do réu que inviabiliza a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas - Bis in idem não caracterizado, pois o aumento na segunda etapa e a impossibilidade de aplicação do privilégio na terceira fase são efeitos distintos decorrentes do mesmo instituto - Inviável, também, a substituição

da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis, por força do disposto nos artigos 44, incisos I e II, e 77, caput, e inciso I, ambos do CP - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Recurso desprovido." (TJSP - Apelação 0003941-43.2015.8.26.0127 - 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Nelson Fonseca Junior - j. 14/09/2017) -g.n.

"TRÁFICO DE DROGAS - pretendida a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para posse de entorpecentes para uso próprio - não acolhimento - materialidade, autoria e FINALIDADE MERCANTIL comprovadas - maus antecedentes e reincidência impedem a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e justificam o aumento na pena-base, não caracterizando bis in idem - penas e regime inicial fechado adequadamente estabelecidos - condenação ao pagamento de custas processuais decorre de expressa obrigação legal - recursos NÃO providos". (TJSP - Apelação Criminal 0000600-92.2018.8.26.0615. Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Amaro Thomé - j. 18/08/2020) - g.n.

Anoto, por fim, que não é cabível a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, porquanto o tempo de prisão provisória do réu ainda não é suficiente para progressão de regime.

Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, diante da ausência de elementos para se verificar as condições econômicas do réu.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e seu aditamento, e CONDENO o réu PAULO HENRIQUE DA SILVA a cumprir seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar seiscentos e oitenta dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, "caput", c.c. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Tendo em vista que, de acordo com os elementos acima analisados, restou demonstrado que a quantia apreendida é decorrente do tráfico, com fundamento no artigo 63, "caput" da Lei 11.343/06, decreto seu perdimento em favor da União.

Diante dos maus antecedentes e considerando a maior gravidade do crime em comento, considerado hediondo, bem assim as circunstâncias concretas do caso, as quais evidenciaram maior gravidade da conduta, conforme acima exposto, verifica-se real possibilidade de reiteração criminosa. Assim, continuam presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual fica mantida, não se aplicando ao caso a tese invocada pela defesa de que todos os acusados de tráfico de drogas devem ser postos imediatamente em liberdade, eis que não se trata de crime na forma privilegiada.

Recomende-se o réu na prisão em que ele se encontra recolhido, servindo-se a presente de ofício.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

P.R.I.C.

Piracicaba, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA